법학입문 · 한동대 법학부 · 조혜신

서술형 모범답안

01 답안 작성 전략

02 문제 1. 노동계약 규제 입법의 필요성 (계약공정)

03 문제 2. 양심적 병역거부: 헌법재판소 구·신 결정 비교

04 문제 3. 공법관계와 사법관계

각 문항: 문제 → 답안 개요 → 모범답안(전문) → 압축 답안(시간 부족 시) → 핵심 키워드

답안 작성 전략

- **공통 구조**: 서론(문제의 소재) → 본론(개념과 전제 → 분석 → 구체적 예·비교) → 결론(평가). 서술형은 결론보다 **논증의 단계**에서 점수가 갈린다.
- **수업 자료를 근거로 쓰기**: 권오승(계약자유와 힘의 균형), 폴라니(노동은 허구 상품), 김유성(노동계약의 종속성), 사회국가원리, 공익·사익 형량, 공법과 사법 슬라이드의 문장을 논거로 연결하면 "수업을 이해한 답안"이 된다.
- **외워 둘 판례 번호**: 헌재 2004. 8. 26. 2002헌가1 / 헌재 2011. 8. 30. 2008헌가22 등 / 헌재 2018. 6. 28. 2011헌바379 등 / 대법원 2018. 11. 1. 2016도10912 전원합의체 / (비교) 간통죄 헌재 2015. 2. 26. 2009헌바17.

※ 문제 2의 조문 표기

문제에는 "헌법 제37조 **제1항** 과잉금지의 원칙"으로 되어 있으나, 과잉금지원칙의 근거는 **헌법 제37조 제2항**("국민의 모든 자유와 권리는 … 필요한 경우에 한하여 법률로써 제한할 수 있으며 … 본질적인 내용을 침해할 수 없다")이다. 제1항은 "헌법에 열거되지 아니한 자유와 권리"의 보장 조항이다. 답안에는 제37조 제2항으로 쓰는 것이 정확하다.

- **문항 간 연결**: 문제 1의 노동법은 문제 3에서 말하는 "사법의 공법화(사회화)"의 대표 예이고, 문제 2의 과잉금지 심사는 문제 3의 "공익과 사익의 형량"의 구체적 적용이다. 한 문항에서 다른 문항의 개념을 한 줄씩 끌어오면 답안의 깊이가 달라진다.

문제 1. 노동계약 규제 입법의 필요성

문제

사적자치와 계약자유의 원칙에도 불구하고, 계약공정의 관점에서 사인 간 노동(근로)계약을 규제하기 위한 입법이 필요한 이유를 구체적인 예를 들어 설명하시오. (노동계약 분쟁해결 및 입법 활동에서 다루었던 쟁점들 참고)

답안 개요

1. **서론**: 사적자치·계약자유의 의의 → 그런데 왜 노동계약만은 합의 내용까지 국가가 통제하는가?
2. **계약자유의 정당성과 전제**: 주관적 정당성 vs 객관적 정당성, 전제는 "힘의 균형"(인식가능성 + 실현가능성) → 무너지면 계약공정의 원리
3. **노동계약에서 전제가 무너지는 이유**: ① 허구 상품(폴라니) ② 거절할 수 없는 판매자(경제적 종속) ③ 계속되는 인적 종속 ④ 민법(임의규정, 제660조, 제103·104조)의 한계
4. **입법의 근거와 방식**: 헌법 제32조 제3항·제33조·제34조, 근로기준법 제3·4·15조(최저기준, 부분 무효와 보충)
5. **구체적 예**: 최저임금 미달 합의 / 장시간 노동과 주 52시간제 / 해고 분쟁과 분쟁해결 연속선 / 5인 미만 사업장·중대재해처벌법
6. **규제의 한계**: 최저기준 + 집단적 자치 = 계약자유의 부정이 아니라 회복
7. **결론**: 노동은 상품이 아니다, 계약공정은 인간 존엄의 문제

모범답안

Ⅰ. 서론: 계약자유의 약속과 노동계약의 역설

근대 사법(私法)은 봉건적 신분 질서에서 해방된 **개인**을 유일한 현실적 기본 단위로 삼아 법질서를 다시 짰다. 그 중심에 있는 **사적자치의 원칙**은 "자기의 일을 자기결정에 따라 자기책임으로 자기지배한다"는 것이며, 여기에서 **소유권 존중·계약자유·과실책임**이라는 근대 민법의 3대 원칙이 나온다. 헌법재판소도 계약자유를 헌법상 행복추구권에 함축된 일반적 행동자유권에서 파생되는 것으로 본다. 이 원칙대로라면 노동관계 역시 노무 제공과 보수 지급을 맞바꾸는 유상·쌍무의 채권계약, 곧 민법 제655조의 고용계약에 지나지 않으며, 근로조건은 당사자의 합의에 맡겨져야 한다.

그런데 현행 법질서는 근로기준법·최저임금법·중대재해처벌법 등으로 노동계약의 내용에 깊숙이 개입하고, 당사자가 합의한 근로조건이라도 법정 기준에 못 미치면 무효로 만든다. 사적자치를 기본원리로 삼는 법질서가 왜 유독 노

동계약에서는 당사자의 합의를 넘어 계약 내용을 직접 통제하는가. 이 물음의 답은 **계약자유가 정당성을 갖기 위한 전제가 무엇인지**, 그리고 **노동계약에서 그 전제가 어떻게 무너지는지**를 살펴볼 때 드러난다.

Ⅱ. 계약자유의 정당성과 그 전제: 힘의 균형

1. 계약자유가 정당한 이유

계약자유의 사상은 모든 개인이 합리적 판단 능력과 윤리적 자율성을 갖춘 이성적 존재라는 근대적 인간관에 기초한다. 각 당사자는 자기 이익을 추구하지만, 계약은 상대방의 동의 없이는 성립하지 않으므로 그 이기심은 합의 과정에서 서로 조정된다. 그래서 자유로운 합의의 결과는 당사자 사이의 **조정적 정의**를 실현한 것으로 받아들여지고, 국가는 그 내용이 제3자(특히 법관)의 눈에 다소 불공평해 보이더라도 그대로 승인해야 한다.

2. 주관적 정당성과 객관적 정당성

그러나 이렇게 승인되는 정당성은 당사자가 스스로 원했다는 데서 나오는 **주관적 정당성**일 뿐, 계약 내용 자체가 공정하다는 **객관적 정당성**이 아니다. 국가가 주관적 정당성만으로 계약을 승인할 수 있는 것은 당사자의 **자기결정이 실질적으로 보장된다는 전제**가 있을 때뿐이다. 자기결정이 실질적이려면 각 당사자가 계약 내용을 정확히 **인식**할 수 있어야 하고(정신적·심리적 대등성, 즉 인식가능성), 자신에게 불리한 계약을 **거절**할 수 있어야 한다(경제적 대등성, 즉 실현가능성). 이를 위해서는 당사자 사이에 일정한 **힘의 균형**이 있고, 시장에서 자유롭고 공정한 경쟁이 이루어져야 한다.

3. 전제가 무너질 때: 계약공정의 원리

이 전제가 무너진 곳에서 계약자유를 고집하면, 계약자유는 **강자가 경제적 약자를 지배하는 수단**으로 전락한다. 형식은 '합의'이지만 실질은 한쪽 당사자의 일방적 결정이 계약의 이름으로 정당화되기 때문이다. 그러므로 자기결정이 보장되지 않는 경우에는 국가가 공평한 제3자의 관점, 즉 객관적 정당성의 기준으로 계약 내용을 통제해야 한다. 이것이 **계약공정의 원리**이며, 근대 사법이 **사회적 조화의 원칙**에 따라 수정된 모습이다. 구체적인 인간은 근대법이 상정한 것처럼 자유롭고 평등하며 독립적인 존재가 아니라, 사용자와 근로자, 임대인과 임차인, 제조자와 소비자처럼 경제적·사회적으로 불평등한 관계 속에 놓여 있다. 약관규제법, 주택임대차보호법, 소비자 관련 법률과 함께 근로기준법이 계약공정을 실현하는 대표적 입법으로 꼽히는 이유가 여기에 있다.

Ⅲ. 노동계약에서 계약자유의 전제가 무너지는 이유

1. 노동력이라는 '허구 상품'

시민법상 계약의 원형은 상품의 등가교환, 곧 매매다. 그러나 노동력은 그것을 지닌 사람의 몸과 분리될 수 없다. **칼 폴라니**가 지적했듯 노동은 "인간 활동의 다른 이름"일 뿐 판매를 위해 생산된 것이 아니며, 사람과 떼어 내 비축하거나 동원할 수 없다. 노동력을 다른 상품처럼 소유자의 처분에 맡기면, 결국 노동력이라는 꼬리표를 단 '사람'의 육체적·심리적·도덕적 실체까지 처분하게 된다. 노동계약에서 거래되는 상품의 사용가치는 **살아 있는 인간의 노동**이다. 그래서 근로시간·안전·휴식·임금은 단순한 거래 조건이 아니라 생명과 건강, 인격이 걸린 조건이며, 이를 오로지 당사자의 흥정에 맡겨 둘 수 없다.

2. 거절할 수 없는 판매자: 경제적 종속

인클로저 운동 이래 생산수단에서 분리된 노동자는 노동력을 팔지 않고는 생존할 수 없다. 게다가 노동력은 저장할 수 없어서 오늘 팔지 못한 노동은 그대로 사라진다. 노동자는 **기다릴 수 없는 판매자**인 반면, 사용자는 다른 노동자를 고를 수 있다. 결국 근로조건은 사실상 사용자가 정하고 노동자는 수락 여부만 고르는 구조가 되며, 계약자유의 핵심인 **불리한 계약을 거절할 자유**가 노동자에게는 형식으로만 존재한다. 임금이 투입된 노동의 양이 아니라 노자 간 **사회적 관계, 곧 힘의 차이**로 결정되고, 그 결과가 공정한 수준이라는 보장이 없는 이유가 여기에 있다.

3. 계약 이후에도 계속되는 인적 종속

노동계약은 노동자가 자기 노동력의 처분권을 상대방에게 **계속적으로** 맡기고, 그 **지휘·명령 아래 종속적 노동**에 종사하는 계약이다. 매매처럼 이행과 동시에 관계가 끝나지 않고, 계약을 체결한 뒤에도 노동자는 사용자의 지휘권 아래에서 일상을 보낸다. 따라서 힘의 불균형은 계약 체결 순간뿐 아니라 이행의 전 과정에 작용하고, 직장 내 괴롭힘처럼 계약서로는 포착할 수 없는 인격적 침해가 생길 수 있다. 또한 관계가 계속되는 동안 노동자는 해고를 걱정해 계약상 권리조차 주장하기 어렵다.

4. 민법의 한계

민법의 고용 규정(제655조~제663조)은 대부분 **임의규정**이어서 근로조건의 최저선을 정하지 않는다. 오히려 **제660조**는 기간의 약정이 없는 고용을 각 당사자가 언제든지 해지 통고할 수 있게 하여 사용자에게 사실상의 해고 자유를 준다. 사적자치의 내재적 한계로 반사회질서 법률행위(제103조), 불공정한 법률행위(제104조), 신의성실의 원칙이 있지만, 노동자 보호 수단으로는 부족하다. 첫째, 제104조는 궁박·경솔·무경험과 현저한 불공정에 더해 판례상 상대방의 이용 의사까지 요구하므로 요건이 엄격하다. 둘째, 개별 소송을 통한 **사후적** 구제에 의존하는데, 고용관계가 계속되는 동안 노동자가 사용자를 상대로 소를 제기하기는 어렵다. 셋째, 효과가 법률행위의 **무효**여서, 근로계약 자체가 무효가 되면 노동자는 보호받기는커녕 일자리를 잃는 역설이 생긴다. 이 때문에 노동관계에는 시민법 원리와 구별되는 독자적 법원리, 곧 국가가 계약 내용을 **사전적·일률적으로** 규율하는 **사회법으로서의 노동법**이 필요하다.

IV. 입법적 규제의 헌법적 근거와 규율 방식

1. 헌법이 명령하는 입법

노동계약 규제는 입법자의 정책 선택에 그치지 않고 헌법이 요구하는 것이다. **헌법 제32조 제1항**은 국가에 적정임금 보장 노력과 최저임금제 시행 의무를 지우고, **제3항**은 "근로조건의 기준은 인간의 존엄성을 보장하도록 법률로 정한다"고 하여 근로조건을 법률로 정하도록 직접 명령한다. **제33조의 노동3권**은 개별 노동자의 열세를 단결이라는 집단의 힘으로 보완하게 하고, **제34조**의 인간다운 생활을 할 권리와 **사회국가원리**는 국가가 국민 각자가 실제로 자유를 행사할 수 있는 실질적 조건을 마련할 의무를 진다는 점을 확인한다. 한편 이러한 규제는 사용자의 계약자유·직업의 자유·재산권을 제한하므로, **헌법 제37조 제2항**의 공공복리 요건과 과잉금지원칙의 범위 안에서 정당화되어야 한다.

2. '최저기준'과 '부분 무효·보충'이라는 입법 기술

근로기준법은 계약자유를 전면 부정하지 않는다. **제3조**는 이 법의 근로조건이 **최저기준**이라고 선언하고 그 이상은 당사자에게 맡긴다. **제4조**는 근로조건을 근로자와 사용자가 "**동등한 지위에서 자유의사에 따라**" 결정해야 한다고 하여, 규제의 목적이 계약자유의 실질적 회복에 있음을 밝힌다. 가장 핵심적인 장치는 **제15조**다. 이 법의 기준에 못 미치는 근로조건은 **그 부분만** 무효가 되고(강행적 효력), 무효가 된 부분은 **법이 정한 기준으로 채워진다**(보충적 효

력). 이는 민법 제104조가 계약 전체를 무효로 만들어 노동자를 오히려 곤란하게 하는 문제를 해결하면서, 계약은 살리고 불공정한 내용만 바로잡는 정교한 방식이다. 최저임금법 제6조 제3항도 같은 구조이며, 제28조는 위반 사용자를 형사처벌하여 **공법적 강제**로 실효성을 확보한다. 그 밖에 해고 제한(제23조), 임금 지급 원칙(제43조), 법정 근로시간(제50조), 직장 내 괴롭힘 금지(제76조의2)가 같은 취지로 계약 내용을 규율한다.

Ⅴ. 구체적 예: 분쟁해결과 입법 활동의 쟁점

1. 최저임금에 못 미치는 '합의'

편의점에서 일하는 대학생 A가 "경험을 쌓는 일이니 최저임금보다 낮은 시급도 괜찮다"고 사업주와 합의했다고 하자. 강박이나 사기가 없으므로 민법상으로는 유효한 의사표시다. 그러나 A의 동의는 일자리를 잃을 수 있다는 압박 아래에서 나온 것으로, **주관적 정당성은 있어도 객관적 정당성은 없다**. 최저임금법 제6조 제3항에 따라 미달 부분은 무효가 되고 최저임금액을 지급하기로 한 것으로 본다. 노동자 자신이 동의했는데도 무효로 하는 것은 온정주의가 아니라, 그 동의가 계약자유를 정당화할 만한 자기결정이 아니었기 때문이다. 흥정을 개별 노동자에게 맡기면 서로 더 낮은 임금을 받아들이는 **바닥으로의 경쟁**이 일어나 모든 노동자의 근로조건이 함께 낮아진다는 점도 최저기준을 법률로 정해야 하는 이유다.

2. 장시간 노동과 주 52시간제

노동자가 더 많은 수당을 받으려고 주 60시간이 넘는 근무에 '자발적으로' 동의하는 경우도 있다. 그러나 낮은 기본급 구조 아래에서 장시간 노동은 생계를 위해 사실상 강제된 선택이며, **처분할 수 없는 법익인 건강과 생명**을 해친다. 수업 자료가 보여 주듯 장시간 노동은 산업재해의 위험을 높인다. 근로기준법 제50조는 1주 40시간, 1일 8시간을 원칙으로 하고, 2018년 개정으로 '1주는 7일'임을 명시하여 연장근로를 포함한 주 최대 근로시간을 **68시간에서 52시간**으로 줄였다(300인 이상 사업장부터 단계적 시행). 입법 토론에서는 업종 특성과 노동자의 선택권을 들어 근로시간을 유연화하자는 주장('주 최대 69시간' 논란)과 노동시간 단축이라는 정책 기조를 지켜야 한다는 주장이 맞섰다. 계약공정의 관점에서 보면 유연화는 노동자가 **실질적으로 거부할 수 있는 조건**, 곧 충분한 기본급, 근로자대표를 통한 집단적 합의, 연속휴식 같은 건강 보호 장치가 갖추어진 범위에서만 정당화될 수 있다.

3. 해고 분쟁과 분쟁해결의 구조

근로계약서에 "회사는 언제든지 계약을 해지할 수 있다"는 조항이 있다면 민법 제660조 아래에서는 유효한 해지권 유보다. 그러나 근로기준법 **제23조**는 **정당한 이유 없는 해고**를 금지하고, 노동자는 **노동위원회**에 부당해고 구제를 신청하거나 법원에 해고무효확인을 구할 수 있다. 수업에서 본 분쟁해결의 연속선, 즉 **당사자 간 의사결정(협상 등) → 사적 제3자의 결정 → 법적 권위를 가진 제3자의 결정(사법결정·입법결정) → 법외적 강제**에 비추어 보면, 힘이 대등하지 않은 노사 분쟁을 당사자 간 협상에만 맡기면 결과는 힘의 차이를 그대로 반영할 뿐이다. 그래서 행정적·사법적 구제라는 **공적 제3자의 개입**을 입법으로 보장하고, 나아가 해고 사유와 절차 같은 일반 규칙을 **입법결정**으로 미리 정해 두어야 분쟁을 공정하게 해결할 수 있다. 노동3권이 보장하는 단체교섭과 단체행동은 개별적으로는 불가능한 대등한 교섭을 집단의 힘으로 가능하게 하는, 법이 제도화한 장치다.

4. 보호의 사각지대와 새로운 입법 쟁점

입법 활동에서 다룬 쟁점들은 계약공정의 원리를 어디까지 넓혀야 하는지 보여 준다. **상시 4명 이하 사업장**에는 해고 제한, 연장·야간·휴일근로 가산수당, 연차휴가, 근로시간 제한 등 근로기준법의 핵심 규정이 적용되지 않는다. 교섭력이 가장 약한 영세 사업장 노동자가 오히려 보호에서 빠지는 역설이다. 다만 영세 사업주의 부담도 실재하므로,

사용자의 직업의 자유·재산권과 노동자 보호를 **이익형량**하여 단계적으로 적용을 넓히고 지원책을 함께 마련하는 것이 바람직하다. 또 **중대재해처벌법**이 경영책임자에게 안전보건 확보의무를 지우고 사망사고 시 1년 이상의 징역 또는 10억 원 이하의 벌금을 과하는 것은, 과실책임 원칙을 수정해 **위험을 지배하는 자에게 책임을 귀속**시키는 무과실책임·위험책임의 논리와 같은 선상에 있다. 산업재해의 위험은 계약으로 노동자에게 떠넘길 수 없다는 것이다. 업종별·지역별 **최저임금 차등 적용** 논쟁 역시 최저기준의 보편성과 개별 산업의 현실을 어떻게 조화시킬지의 문제다.

VI. 규제의 한계: 계약자유의 부정이 아니라 회복

노동계약 규제가 정당하다고 해서 국가가 근로조건 전부를 정해야 한다는 뜻은 아니다. 과도하고 획일적인 규제는 고용을 위축시키고 업종의 다양한 현실을 무시할 수 있으며, 사용자의 기본권을 과잉 제한할 수 있다. 그래서 노동법은 **두 겹의 구조**를 취한다. 국가는 개별적 근로관계법으로 인간의 존엄을 위한 **바닥(최저기준)**을 정하고, 그 위의 근로조건은 노동3권에 기초한 단체교섭, 곧 **집단적 자치**에 맡긴다. 이는 사적자치를 폐기하는 것이 아니라, 개별 노동자 차원에서는 불가능했던 대등한 자기결정을 법정 최저기준과 집단적 자치를 통해 **복원**하는 것이다.

VII. 결론

근대 사법이 약속한 자유는 대등한 당사자를 전제로 한다. 형식적으로 평등한 자유가 실질적 불평등 위에서 작동하면 강한 자를 더 강하게 만들 뿐이며, 바로 이 문제를 해결하려고 등장한 것이 사회국가원리다. 노동계약은 거래 대상이 인간 자신과 분리될 수 없고, 노동자가 거절할 수 없는 처지에서 계약을 맺으며, 계약 이후에도 종속 관계가 이어진다는 점에서 그 불균형이 가장 뚜렷한 영역이다. 그러므로 노동계약에 대한 입법적 규제는 계약자유를 침해하는 것이 아니라, **계약자유가 본래 약속한 자기결정과 정의를 노동의 영역에서 실현하는 조건**이다. 1944년 ILO 필라델피아 선언이 "**노동은 상품이 아니다**"라고 천명하고, 우리 헌법이 근로조건의 기준을 인간의 존엄성에 맞게 법률로 정하도록 한 것은, 계약의 공정이 결국 **인간 존엄의 문제**임을 확인한 것이다.

압축 답안 (시간이 부족할 때)

사적자치와 계약자유는 합리적·자율적 개인을 전제로, 합의 과정에서 이익이 조정된다는 **주관적 정당성**에 기초한다. 그러나 이는 당사자가 계약 내용을 인식하고 불리한 계약을 거절할 수 있는 **힘의 균형**을 전제로 하며, 그 전제가 무너지면 계약자유는 강자가 약자를 지배하는 수단이 되므로 국가가 객관적 정당성의 관점에서 계약 내용을 통제해야 한다(**계약공정의 원리**). 노동계약은 ① 노동력이 인간의 몸·인격과 분리될 수 없는 허구 상품이고(폴라니), ② 생산수단에서 분리된 노동자는 노동력을 팔지 않고는 생존할 수 없어 거절할 자유가 없으며, ③ 계약 후에도 지휘·명령 아래 인적 종속이 계속되고, ④ 민법의 고용 규정은 임의규정이며 제103·104조는 요건이 엄격하고 전부 무효라는 효과 때문에 노동자 보호에 맞지 않는다는 점에서 이 전제가 가장 뚜렷이 무너진다. 그래서 헌법 제32조 제3항은 근로조건의 기준을 인간의 존엄성에 맞게 법률로 정하도록 하고, 근로기준법은 최저기준(제3조)에 못 미치는 부분만 무효로 하고 법정 기준으로 채운다(제15조). 예컨대 최저임금 미달 합의는 노동자가 동의했어도 최저임금법 제6조 제3항에 따라 미달 부분이 무효이고, 건강과 생명을 해치는 장시간 노동 합의는 주 52시간제로 제한되며, "언제든 해고" 조항은 근로기준법 제23조에 반하고 노동위원회·법원이라는 공적 제3자를 통해 구제된다. 5인 미만 사업장 적용 제외, 중대재해처벌법 같은 입법 쟁점도 같은 원리에서 접근해야 한다. 이러한 규제는 계약자유의 부정이 아니라, 최저기준과 집단적 자치를 통해 노동의 영역에서 실질적 자기결정을 회복하는 것이다.

핵심 키워드

사적자치(자기결정·자기책임) · 주관적/객관적 정당성 · 힘의 균형(인식가능성·실현가능성) · 계약공정의 원리 · 사회적 조화의 원칙 · 허구 상품(폴라니) · 종속적 노동(김유성) · 민법 제660조·제104조의 한계 · 헌법 제32조 제3항 · 근로기준법 제3·4·15·23·50조 · 최저임금법 제6조 제3항 · 분쟁해결 연속선 · 5인 미만 사업장 · 중대재해처벌법 · 집단적 자치 · 노동은 상품이 아니다

문제 2. 양심적 병역거부: 헌법재판소 구·신 결정 비교

문제

구 병역법 제5조 제1항이 양심적 병역거부자를 위한 대체역 복무를 정하지 않고 있는 것이 헌법 제19조에서 보장하는 양심의 자유에 대한 침해인지 여부에 대한 (헌법 제37조 제1항 과잉금지의 원칙 심사에 따른) 헌법재판소의 구 결정과 신 결정을 비교하여 설명하시오.

답안 개요

1. **문제의 소재**: 양심적 병역거부의 의미, 병역종류조항과 처벌조항, 심사 기준은 헌법 제37조 제2항 과잉금지원칙
2. **공통 전제**: 양심의 정의, 양심형성의 자유 vs 양심실현의 자유, 부작위에 의한 양심실현의 자유
3. **구 결정(2004·2011)**: 처벌조항 심사, 넓은 입법재량·완화된 심사, 최소성·균형성 충족 → 합헌 + 입법 권고
4. **신 결정(2018)**: 병역종류조항 직접 심사(부진정입법부작위), 최소성·균형성 위반 → 헌법불합치(6:3), 처벌조항 합헌(4:4:1)
5. **비교**: 심판대상 / 심사 강도와 입증 부담 / 형량 모델(양자택일→조화) / 양심의 자유 이해 / 결론(권고→명령), 변화의 배경
6. **결론과 평가**: 소수자 양심의 헌법적 무게, 현행 대체복무(36개월·교정시설)의 과제

모범답안

Ⅰ. 문제의 소재

양심적 병역거부란 종교적·윤리적·철학적 또는 이와 유사한 동기에서 형성된 양심상의 결정을 이유로 집총이나 군사훈련을 수반하는 병역의무의 이행을 거부하는 것을 말한다. 여기서 '양심적'이라는 말은 병역거부가 도덕적으로 옳다는 평가가 아니라, 그 결정이 '양심에 따른' 것이라는 뜻이다. 비폭력 평화주의는 초기 기독교 전통(295년 병역을 거부하다 처형된 막시밀리아누스)에서 재세례파(메노나이트, 아미쉬)로 이어진 오랜 신앙 전통이며, 우리나라에서는 주로 여호와의 증인 신도들이 병역을 거부하여 매년 수백 명이 1년 6개월의 실형을 선고받아 왔다.

구 병역법 **제5조 제1항(병역종류조항)**은 병역의 종류를 현역·예비역·보충역·제1국민역·제2국민역(이후 병역준비역·전시근로역)으로 한정하였고, 이들은 모두 **군사훈련을 전제**로 하였다. 군사훈련이 없는 대체역이 없었으므로, 양심적 병역거부자에게는 양심을 버리고 입영하거나 **제88조 제1항(처벌조항)**에 따라 3년 이하의 징역형을 받는 길밖에 없었다. 쟁점은 이처럼 대체복무를 규정하지 않은 것이 **헌법 제19조 양심의 자유**를 침해하는지이며, 그 판단 기준은 기본권 제한의 한계를 정한 **헌법 제37조 제2항의 과잉금지원칙**(목적의 정당성, 수단의 적합성, 침해의 최소성, 법익

의 균형성)이다. 헌법재판소는 2004년과 2011년에는 합헌으로 보았으나, 2018년에는 병역종류조항에 대해 헌법불합치를 선고하였다.

Ⅱ. 공통 전제: 양심의 자유와 제한되는 기본권

헌법재판소는 구·신 결정 모두에서 양심을 "어떤 일의 옳고 그름을 판단함에 있어서 그렇게 행동하지 아니하고는 **자신의 인격적인 존재가치가 허물어지고 말 것이라는 강력하고 진지한 마음의 소리**"로 정의한다. 양심의 자유는 내심에서 양심을 형성하고 결정하는 **양심형성의 자유**와, 형성된 양심을 밖으로 표명하고 실현하는 **양심실현의 자유**를 포함한다. 앞의 것은 절대적으로 보장되지만, 뒤의 것은 타인의 기본권이나 공동체의 법익과 충돌할 수 있으므로 법률로 제한할 수 있다. 양심적 병역거부는 양심에 반하는 행동을 강요받지 않을 자유, 즉 **부작위에 의한 양심실현의 자유**의 문제다. 이와 맞서는 법익은 헌법 제39조 국방의 의무로 구체화되는 **국가안보**와 **병역의무의 공평한 부담**이다.

Ⅲ. 구 결정: 합헌 (헌재 2004. 8. 26. 2002헌가1 / 헌재 2011. 8. 30. 2008헌가22 등)

1. 심판대상과 판단 구조

구 결정은 **처벌조항**(구 병역법 제88조 제1항 제1호)을 심판대상으로 삼았다. 대체복무를 규정하지 않은 문제는 처벌조항의 침해 최소성 단계에서 '형사처벌보다 덜 침해적인 대안이 있는가'라는 형태로 **간접적으로** 다루어졌다.

2. 심사 강도: 넓은 입법재량과 완화된 심사

2004년 결정은 양심의 자유의 특수성을 강조하였다. 일반적인 기본권 제한에서는 공익과 사익을 형량해 양쪽을 조화시킬 수 있지만, 양심의 자유는 양심에 반하는 행동을 강요받느냐 받지 않느냐의 **양자택일** 구조여서 법익 형량을 통한 조화가 어렵다고 보았다. 나아가 양심의 자유는 양심을 이유로 법적 의무의 이행을 거부하거나 **대체의무를 요구할 권리를 주는 것이 아니라**, 국가에 대해 가능하면 양심을 **고려**하고 보호해 달라고 요구하는 권리에 그친다고 하였다. 국가안보와 직결된 병역제도의 형성에는 입법자에게 **넓은 형성재량**이 있으므로, 대체복무제를 도입하지 않은 입법자의 판단이 현저히 불합리하거나 명백히 잘못된 것인지만 심사하는 **완화된 심사(명백성 통제)**를 택하였다. 2011년 결정은 과잉금지원칙의 네 요소를 차례로 심사했지만, 국가안보의 특수성을 들어 입법자의 판단을 넓게 존중했다는 점에서 같은 흐름에 있다.

3. 과잉금지원칙의 단계별 판단

목적의 정당성과 수단의 적합성은 쉽게 인정되었다. 병역자원을 확보하고 병역부담의 형평을 기하여 국가안보를 실현하려는 목적은 정당하고, 형벌로 병역의무 이행을 강제하는 것은 그 목적에 적합하다는 것이다.

핵심인 **침해의 최소성**에서 구 결정은 대체복무제를 도입할 경우의 위험을 근거로 들었다. ① 남북이 대치하는 특수한 안보 상황, ② 병력자원의 손실 가능성, ③ 진정한 양심과 병역기피를 위한 '위장' 양심을 가려내기 어렵다는 점, ④ 병역의무의 형평성이 무너져 국민 사이에 위화감이 생기고 사회적 공감대도 부족하다는 점이다. 이런 사정에 비추어 대체복무제가 처벌조항과 **같은 효과로** 입법목적을 달성할 수 있다고 단정할 수 없으므로, 침해의 최소성에 반하지 않는다고 판단하였다.

법익의 균형성에서는 국가의 존립과 국민 전체의 안전이라는 공익이 대단히 중대하므로 병역거부자가 입는 불이익보다 크다고 보았다.

4. 결론과 한계

구 결정은 **합헌**으로 결론 내렸다(2004년 결정은 재판관 7:2). 다만 2004년 결정은 입법자에게 양심의 자유와 국가안보를 공존시킬 대안이 있는지 검토하라고 **권고**하였다. 기본권 보호의 필요성을 인식하면서도 그 해소를 입법자의 선의에 맡긴 셈인데, 대체복무제 도입은 이후 오랫동안 실현되지 않았다.

IV. 신 결정: 병역종류조항 헌법불합치 (헌재 2018. 6. 28. 2011헌바379 등)

1. 심판대상의 전환

신 결정은 **병역종류조항을 직접 심판대상**으로 삼았다. 병역의 종류를 정하는 입법을 하면서 군사훈련이 없는 대체역을 포함하지 않은 것은 입법을 전혀 하지 않은 경우(진정입법부작위)가 아니라 입법 내용이 **불완전·불충분한 경우(부진정입법부작위)**이므로, 그 조항 자체를 과잉금지원칙에 따라 심사할 수 있다고 보았다.

2. 과잉금지원칙의 단계별 판단

목적의 정당성과 수단의 적합성은 구 결정처럼 인정되었다. 병역의 종류를 한정적으로 열거하고 예외를 두지 않아 병역자원을 효과적으로 확보하려는 것은 국가안보라는 헌법적 법익을 실현하기 위한 것이고, 병역종류조항은 그 목적을 달성하는 데 적합한 수단이라는 것이다.

결론이 갈린 곳은 **침해의 최소성**이다. 헌법재판소는 현역·예비역·보충역·병역준비역·전시근로역이 **모두 군사훈련을 전제**하므로 양심적 병역거부자에게는 양심과 형벌 사이의 선택만 남는다는 점을 지적하고, 구 결정이 들었던 우려를 하나씩 검토하였다. ① 양심적 병역거부자는 연간 수백 명 수준으로 전체 병역자원에 비하면 극히 적고, 처벌을 받아도 결국 교도소에 수감될 뿐 **병력으로 활용되지 않으므로**, 대체복무제를 도입해도 병역자원은 줄지 않는다. 형벌을 감수하면서까지 거부하는 이들에게 처벌은 병역 이행을 끌어내는 효과도 거의 없다. 국방력에서 병력 규모가 차지하는 비중도 과학기술의 발전으로 낮아졌다. ② 엄격한 사전 심사와 사후 관리, 현역보다 길거나 고된 복무를 설계하면 **위장 병역거부를 막을 수 있다**. ③ 대체복무의 기간과 강도를 현역과 실질적으로 같게 설계하면 **병역의무의 형평성**도 지킬 수 있다. ④ 많은 국가가 대체복무제를 도입하였고, 유엔 자유권규약위원회 등 국제기구도 우리나라에 대체복무제 도입을 거듭 권고하였다. 결국 **대체복무제라는 덜 침해적인 대안이 있는데도** 군사훈련을 수반하는 병역만 규정한 것은 침해의 최소성에 어긋난다.

법익의 균형성도 부정되었다. 대체복무제를 도입해도 국가안보와 병역의무의 형평이라는 공익은 충분히 달성할 수 있다. 반면 대체복무가 없어 양심적 병역거부자가 감수해야 하는 불이익은 **심대**하다. 1년 6개월 이상의 징역형을 받고, 형 집행 후에도 공무원 임용 제한과 각종 관허업 인허가 제한을 받으며, 전과자라는 사회적 낙인 속에서 살아가야 한다.

3. 결론: 헌법불합치와 입법 명령

헌법재판소는 병역종류조항이 과잉금지원칙에 위배되어 양심의 자유를 침해한다고 보았다(재판관 **6:3**). 다만 단순위헌을 선고하면 병역종류조항 전체의 효력이 사라져 병역의무를 부과할 근거 자체가 없어지므로, **헌법불합치**를 선고하고 **2019년 12월 31일**까지 개선입법을 하도록 하면서 그때까지 계속 적용을 명하였다.

같은 결정에서 **처벌조항은 합헌**으로 유지되었다(재판관 4(합헌):4(일부위헌):1(각하)로 위헌 정족수 6인에 못 미침). 합헌 의견은 처벌조항이 '정당한 사유 없는' 병역기피를 처벌하는 조항으로서 그 자체로는 과잉금지원칙에 반하지

않으며, 양심적 병역거부자 처벌의 위헌성은 처벌조항이 아니라 **대체복무를 규정하지 않은 병역종류조항의 불완전성**에서 비롯된다고 보았다. 대체복무제가 도입되면 그 복무마저 거부하는 사람을 처벌하면 된다는 것이다.

4. 후속 변화

이 결정 뒤 대법원은 **2018. 11. 1. 전원합의체 판결(2016도10912)**에서 진정한 양심에 따른 병역거부는 병역법 제88조 제1항의 **'정당한 사유'**에 해당한다고 보아 판례를 변경하였다. 국회는 2019년 12월 **「대체역의 편성 및 복무 등에 관한 법률」**을 제정하고 병역법 제5조에 대체역을 신설하였으며, 2020년부터 대체역 심사를 거친 사람이 교정시설에서 **36개월**간 합숙 복무하는 대체복무가 시행되고 있다.

Ⅴ. 구 결정과 신 결정의 비교

구분	구 결정 (2004·2011)	신 결정 (2018)
사건	헌재 2004. 8. 26. 2002헌가1 헌재 2011. 8. 30. 2008헌가22 등	헌재 2018. 6. 28. 2011헌바379 등
심판대상	처벌조항 (병역법 제88조 제1항)	병역종류조항 (제5조 제1항) + 처벌조항
대체복무 문제의 위치	처벌조항의 최소성 판단에서 "대안이 있는가"로 간접 판단	병역종류조항의 부진정입법부작위로 직접 판단
양심의 자유 이해	의무 면제·대체의무 요구권이 아니라 국가에 양심을 "고려"해 달라는 권리	양심에 반하는 행동을 형벌로 강요하는 것은 인격적 존재가치를 무너뜨리는 중대한 제한
심사 강도	넓은 입법재량 존중, 명백성 통제 (완화된 심사)	엄격한 과잉금지 심사, 국가가 제한의 필요성을 정당화
목적·수단	인정	인정
침해의 최소성	남북 대치, 병력 손실, 양심 판정 곤란·위장 거부, 형평성·공감대 부족 → 대안의 효과 불확실 → 충족	거부자 연 수백 명·어차피 수감, 엄격 심사·무거운 복무로 위장 방지, 형평 확보 가능, 국제적 흐름 → 대안 있음 → 위반
법익의 균형성	국가안보의 중대성이 압도 → 충족	공익은 대체복무로 달성 가능, 형사처벌·전과·취업 제한 불이익 심대 → 위반
형량 모델	양자택일 (양심 vs 안보)	조화 (대체복무로 두 법익 공존)
결론	합헌 (2004년 7:2), 대체복무 도입 검토 "권고"	병역종류조항 헌법불합치 (6:3, 2019. 12. 31. 시한) 처벌조항 합헌 (4:4:1)
후속	대체복무 도입 지연	대법원 2016도10912 전합 무죄 / 대체역법(2019) / 2020년부터 36개월 대체복무

1. 심판대상과 위헌성의 위치가 바뀌었다

구 결정은 처벌조항만 보았기 때문에 '대안이 없다'는 사실이 오히려 처벌을 정당화하는 사정으로 작용하였다. 신 결정은 시선을 병역종류조항으로 옮겨, 문제의 본질이 '처벌'이 아니라 **'대안 없는 입법'**에 있음을 밝혔다. 그 결과 처

벌조항은 합헌으로 두되 병역종류조항을 헌법불합치로 결정하여, 입법자에게 대체복무제를 만들 **헌법적 의무**를 지웠다. 2004년의 '권고'가 '명령'으로 바뀐 것이다.

2. 심사 강도와 입증 부담의 방향이 바뀌었다

구 결정은 대체복무제를 도입해도 안보에 지장이 없다는 점이 증명되지 않았다는 이유로 입법자의 판단을 존중하였다. **불확실성의 부담을 기본권 주체에게** 지운 것이다. 신 결정은 병역거부자의 수, 수감되어 병력으로 쓰이지 않는 현실, 해외 사례 같은 구체적 사실을 근거로 대체복무제가 안보를 해친다는 근거가 없다고 판단하였다. 기본권을 제한하는 **국가가 그 필요성을 정당화해야 한다**는 과잉금지원칙의 본래 취지에 더 충실해진 것이다.

3. 이익형량의 모델이 '양자택일'에서 '조화'로 바뀌었다

구 결정은 양심의 자유와 국가안보를 둘 중 하나를 골라야 하는 관계로 보았고, 그 결과 국가안보라는 공익이 우선하였다. 신 결정은 대체복무라는 **제3의 길**로 두 법익을 함께 실현할 수 있다고 보았다. 수업에서 다룬 공익과 사익의 형량 틀로 말하면, 공익을 이유로 사익을 제한하더라도 그 수단은 필요 최소한에 그쳐야 하고, 충돌하는 법익이 모두 최대한 실현되도록 조화를 찾아야 한다는 사고(규범조화적 해결)가 판단의 중심에 놓였다. 대체복무는 병역의무의 **면제가 아니라 이행 방식의 다양화**이므로, 국방의 의무라는 공익을 포기하지 않으면서 소수자의 양심을 보호한다.

4. 양심의 자유에 대한 이해가 깊어졌다

구 결정은 양심의 자유를 국가에 '고려'를 요청하는 권리 정도로 좁게 보았다. 신 결정은 양심에 반하는 행동을 형벌로 강요하는 것이 인격의 존재가치를 무너뜨리는 중대한 제한임을 정면으로 인정하고, 국가가 양심을 보호할 대안을 마련하지 않은 것 자체를 기본권 침해로 보았다.

5. 변화의 배경

이 전환은 헌법재판소가 사회의 변화를 헌법 해석에 반영한 결과다. 양심적 병역거부에 대한 국민 인식의 변화, 하급심 무죄 판결의 증가, 유엔 자유권규약위원회가 2006년 이후 한국의 처벌을 규약 위반으로 판단해 온 국제인권규범의 흐름, 병역자원 구조와 국방 환경의 변화가 함께 작용하였다. 수업에서 다룬 **간통죄**가 네 차례 합헌 결정 뒤 2015년 위헌으로 바뀐 것처럼(헌재 2015. 2. 26. 2009헌바17), 같은 헌법 조문도 공동체의 가치와 사실관계가 바뀌면 다르게 해석될 수 있다.

VI. 결론과 평가

신 결정은 다수의 안보 논리 앞에서 **소수자의 양심이 갖는 헌법적 무게**를 인정하고, 형벌이라는 가장 강한 제재를 대체복무라는 덜 침해적인 수단으로 바꾸라고 요구했다는 점에서 기본권 보장의 진전으로 평가할 수 있다. 이는 헌법 제10조 인간의 존엄과 제19조 양심의 자유를 실질화하고, **관용**을 헌법적 원리로 받아들인 결정이다. 다만 현행 대체복무는 현역 육군(18개월)의 두 배인 36개월을 교정시설에서 합숙하도록 하고 있어 징벌적이라는 비판이 있다. 대체복무가 신 결정의 취지에 맞으려면, 위장 거부를 막을 만큼 엄격하되 처벌과 다름없을 만큼 가혹하지는 않은 **실질적 등가성**을 갖추고 복무 분야를 다양화해야 할 것이다.

압축 답안 (시간이 부족할 때)

구 결정(헌재 2004. 8. 26. 2002헌가1, 2011. 8. 30. 2008헌가22 등)은 처벌조항을 심판대상으로, 양심의 자유를 의무 면제나 대체복무를 요구할 권리가 아닌 국가에 양심의 '고려'를 요청하는 권리로 좁게 보고, 국가안보 분야의 넓은 입법재량을 이유로 완화된 심사를 하였다. 목적의 정당성과 수단의 적합성을 인정한 뒤, 침해의 최소성에서는 남북 대치, 병력 손실, 양심 판정의 어려움과 위장 거부, 형평성·사회적 공감대 부족을 들어 대체복무가 같은 효과를 보장하지 못한다고 보아 충족, 법익균형성도 국가안보의 중대성을 이유로 충족한다고 하여 **합헌**으로 결정하였다(2004년은 대체복무 검토 권고). **신 결정**(헌재 2018. 6. 28. 2011헌바379 등)은 병역종류조항을 부진정입법부작위로 직접 심사하였다. 목적과 수단은 인정했으나, 모든 병역이 군사훈련을 전제하는 상황에서 병역거부자는 연 수백 명에 불과하고 어차피 수감되어 병력이 되지 않으며, 엄격한 심사와 현역보다 무거운 복무로 위장을 막고 형평을 확보할 수 있고, 국제적 흐름도 대체복무를 인정하므로, 덜 침해적인 대안이 있는데도 두지 않아 최소성에 위반되고, 공익은 대체복무로도 달성할 수 있는 반면 형사처벌·전과·취업 제한 등 불이익은 심대하여 균형성도 잃었다고 보아 **헌법불합치**(6:3, 2019. 12. 31. 시한)를 선고하였다. 처벌조항은 합헌(4:4:1)으로 유지되었다. 두 결정은 ① 심판대상과 위헌성의 위치(처벌 → 대안 없는 입법), ② 심사 강도와 입증 부담(입법재량 존중 → 국가의 정당화 책임), ③ 형량 모델(양자택일 → 조화), ④ 결론(권고 → 입법 명령)에서 달라졌다. 이후 대법원 전원합의체(2016도10912)가 양심적 병역거부를 '정당한 사유'로 보아 무죄를 선고하고, 대체역법(2019) 제정으로 36개월 대체복무가 도입되었다.

핵심 키워드

양심의 정의("인격적 존재가치가 허물어지고 말 것이라는 강력하고 진지한 마음의 소리") · 양심형성/양심실현의 자유 · 부작위에 의한 양심실현의 자유 · 헌법 제37조 제2항 과잉금지 4요소 · 명백성 통제 vs 엄격 심사 · 부진정입법부작위 · 병역자원 손실 반박(연 수백 명, 어차피 수감) · 위장 거부 방지(엄격 심사, 무거운 복무) · 헌법불합치 6:3 · 처벌조항 합헌 4:4:1 · 2016도10912 전합 · 대체역법 36개월 · 양자택일 → 조화 · 권고 → 명령

문제 3. 공법관계와 사법관계

문제

공법관계와 사법관계의 의의와 양자의 차이점을 설명하시오.

답안 개요

1. **서론**: 법률관계의 의미, 국가와 사회의 이원론 위의 공·사법 이원 체계, 구별의 실천적 의미
2. **의의**: 사법관계(대등, 사적자치) / 공법관계(행정주체, 공익 실현·법률적합성), 권력관계·관리관계·국고관계, 국가적 공권·개인적 공권
3. **구별 기준**: 이익설·종속설·신주체설 → 종합 판단, 판례 예(협의취득 vs 수용재결, 일반재산 대부 vs 행정재산 사용허가)
4. **차이점 7가지**: 지배 원리 / 형성 방식·절차 / 효력 / 강제 / 손해전보 / 쟁송 / 이익형량 구조
5. **현대적 변용**: 사법의 공법화(사회법) · 공법의 사법화(행정사법), 그래도 구별의 실익은 남음
6. **결론**: 시장과 국가를 구분한 법질서의 기본 설계

모범답안

Ⅰ. 서론: 공·사법 이원론의 의미

법률관계란 법이 규율하는 사람 사이의 생활관계, 곧 권리와 의무의 관계를 말한다. 근대 법질서는 **국가와 사회를 구분하는 이원론** 위에 서 있다. 사회, 특히 시장은 자유롭고 평등한 개인들이 스스로 법률관계를 형성하는 자율의 영역이고, 국가는 공익을 실현하려고 공권력을 행사하되 그 권력이 법에 구속되는 영역이다. 이에 따라 법질서도 **사적자치를 원리로 하는 사법(私法)**과 **공익 실현과 법치행정을 원리로 하는 공법(公法)**으로 나뉜다. 우리 실정법은 행정절차법, 행정소송법, 국가배상법 등에서 공법관계를 사법관계와 다르게 다루므로, 어떤 법률관계가 어느 쪽에 속하는지는 **적용 법규와 구제 절차를 결정하는 실천적 문제**다.

Ⅱ. 공법관계와 사법관계의 의의

1. 사법관계

사법관계는 **대등한 사인 상호 간**의 법률관계다. 여기에는 사적자치의 원칙과 그로부터 나오는 계약자유, 소유권 존중, 과실책임의 원칙이 적용된다. 법률관계는 당사자의 **의사 합치(계약)**로 형성되며, 민법과 상법이 주로 규율한다. 국가나 지방자치단체도 사인과 같은 지위에서 물품을 사거나 일반재산을 파는 경우(**국고관계**)에는 사법관계의 당사자가 된다.

2. 공법관계

공법관계는 국가·지방자치단체 등 **행정주체**가 공권력의 주체 또는 공익 실현의 주체로서 사인과 맺는 법률관계다. 여기에는 **공익 실현**을 중심으로 하는 공법원리가 적용되며, 행정주체는 법률에 근거해 **일방적으로** 법률관계를 형성하거나 바꿀 수 있다. 공법관계는 다시 행정주체가 우월한 지위에서 명령·강제하는 **권력관계**(조세 부과, 경찰처분, 토지수용 등)와, 공익 목적으로 공물이나 사업을 관리·경영하는 비권력적 **관리관계**로 나눌 수 있다. 행정주체가 공법관계에서 우월한 의사주체로서 갖는 권리를 **국가적 공권**(조직권, 재정권, 경찰권, 복리행정권 등)이라 하고, 사인이 공법상 자기 이익을 위해 행정주체에게 일정한 행위를 요구할 수 있는 법적 힘을 **개인적 공권**(헌법상 국민투표권, 지방자치법상 주민투표권 등)이라 한다.

III. 구별 기준

구별 기준으로 여러 학설이 있다. **이익설**은 공익을 위한 법률관계를 공법관계, 사익을 위한 것을 사법관계로 본다. 그러나 사법도 거래의 안전 같은 공익에 이바지하고 공법도 개인적 공권으로 사익을 보호하므로 기준이 모호하다. **종속설(권력설)**은 상하의 지배·복종 관계를 공법관계, 대등한 관계를 사법관계로 본다. 그러나 공법상 계약처럼 대등한 공법관계나, 친권처럼 상하 관계인 사법관계를 설명하지 못한다. **신주체설(귀속설)**은 공권력의 주체에게만 권리·의무를 귀속시키는 법을 공법, 누구에게나 귀속될 수 있는 법을 사법으로 본다. 가장 유력한 기준이지만, 어떤 법규가 공권력 주체로서의 지위에 관한 것인지 다시 해석해야 한다. 그래서 하나의 기준만으로 가르기보다 **관계 법규의 목적과 성질, 법률관계의 주체와 내용을 종합**하여 판단하는 것이 일반적이다. 판례도 같은 토지를 취득하더라도 공익사업법상 **협의취득은 사법상 매매**로, **수용재결은 공법상 처분**으로 보고, 국유 **일반재산의 대부는 사법관계**로, **행정재산의 사용·수익허가는 행정처분**으로 본다.

IV. 양자의 차이점

1. 지배 원리: 사적자치와 법률적합성

사법관계에서는 당사자가 법률관계를 자유롭게 형성하는 **사적자치**가 원칙이다. 반면 공법관계에서 행정청에게는 이러한 '자치'가 허용되지 않는다. 모든 공권력 행사는 개인을 보호하기 위해 합헌적 법률에 따라 이루어져야 한다는 **행정의 법률적합성 원칙**(법률 우위, 법률 유보)이 적용되며, 이는 국민의 대표인 국회가 정한 법률에 행정을 묶어 둔다는 점에서 **민주주의 원리의 표현**이기도 하다. 또한 행정은 **비례원칙, 신뢰보호원칙, 자기구속원칙, 부당결부금지원칙** 같은 행정법의 일반원칙에 구속되며, 비례원칙·신뢰보호원칙·부당결부금지원칙 등은 현재 행정기본법에 명문화되어 있다(자기구속원칙은 평등원칙에서 도출된다). 사법의 신의성실 원칙이 행정법에서는 신뢰보호원칙으로 나타난다는 점에서 두 영역은 서로 대응하기도 한다.

2. 법률관계의 형성 방식과 절차

사법관계는 당사자의 의사 합치로 형성되고 방식도 원칙적으로 자유롭다. 공법관계에서 행정청은 **처분**이라는 일방적 행위로 법률관계를 형성하며, 그 절차는 **행정절차법**이 정한 바(처분의 사전통지, 의견청취, 이유제시 등)에 따라야 한다. 일방적으로 형성할 수 있는 힘을 갖는 대신 절차적 통제를 받는 것이다.

3. 행위의 효력

사인의 법률행위는 하자가 있으면 무효이거나 취소할 수 있고, 그 판단은 결국 법원이 한다. 행정청의 처분은 하자가 있더라도 중대·명백하여 당연무효가 아닌 한 권한 있는 기관이 취소하기 전까지는 유효한 것으로 통용되는 **공정력**을

가지며, 쟁송기간이 지나면 더 이상 다툴 수 없는 **불가쟁력**이 생긴다. 공익 실현의 계속성과 법적 안정성을 위한 특수한 효력이다.

4. 의무 불이행 시의 강제

상대방이 의무를 이행하지 않을 때 **사인은 스스로 강제할 수 없다**. 자력구제는 원칙적으로 금지되며, 법원의 판결을 받아 민사집행 절차를 거쳐야 한다. 반면 **행정청은 법률의 근거가 있으면 법원을 거치지 않고 스스로 의무 이행을 강제**할 수 있다(대집행, 이행강제금, 직접강제, 강제징수 등 행정상 강제집행). 위반에 대해서는 행정벌을 과할 수도 있다.

5. 손해전보

사인의 불법행위로 인한 손해는 **민법 제750조**의 불법행위책임(과실책임)에 따라 배상한다. 공무원이 직무를 집행하면서 저지른 불법행위에 대해서는 **헌법 제29조와 국가배상법**에 따라 국가나 지방자치단체가 배상한다. 나아가 공법관계에는 **적법한** 공권력 행사로 생긴 손실을 메우는 **손실보상** 제도가 있다. 공공필요를 위한 재산권 제한은 사회적 제약의 범위에서는 사인이 참아야 하지만(**수인의무**), 그 침해가 특정인에게만 가혹한 **특별한 희생**에 이르면 국가는 헌법 제23조 제3항에 따라 정당한 보상을 해야 한다. 적법한 행위로 인한 손실을 보상하는 체계는 사법관계에 없는 공법관계의 특징이다.

6. 쟁송 절차

사인 간 분쟁은 **민사소송법**에 따라 민사법원에서 해결한다. 행정주체와 사인 간 분쟁은 **행정소송법**에 따라 항고소송(취소소송, 무효등확인소송, 부작위위법확인소송)이나 당사자소송으로 다투며, 제소기간, 행정심판, 처분청을 피고로 하는 점, 직권심리, 사정판결처럼 공익을 고려한 특수한 규율을 받는다.

7. 이익형량의 구조

사법관계의 갈등은 **대등한 사익 사이의 조정** 문제이므로 신의성실 원칙, 권리남용 금지, 충돌하는 권리 사이의 규범조화적 해결이 중심이 된다. 공법관계의 갈등은 **공익과 사익의 형량** 문제다. 공공복리를 위해 법률로 사익을 제한할 수 있지만(헌법 제37조 제2항), 그 제한은 **과잉금지원칙**을 지켜야 하고 기본권의 **본질적 내용**을 침해할 수 없다.

구분	사법관계	공법관계
당사자	대등한 사인 상호 간 (국고관계 포함)	행정주체(공권력·공익 실현 주체)와 사인
지배 원리	사적자치 (계약자유·소유권 존중·과실책임)	공익 실현, 법률적합성(법률 우위·유보), 행정법 일반원칙
형성 방식	의사 합치(계약), 방식 자유	처분 등 일방적 형성, 행정절차법
효력	하자 있으면 무효·취소 (법원 판단)	공정력, 불가쟁력
의무 불이행	자력강제 불가 → 판결·민사집행	행정상 강제집행(대집행·이행강제금·직접강제·강제징수), 행정벌
권리	사권 (처분·포기 자유)	국가적 공권 / 개인적 공권
손해전보	민법 제750조 불법행위책임	국가배상법(헌법 제29조), 손실보상(헌법 제23조 제3항)
쟁송	민사소송법 (민사법원)	행정소송법 (항고소송·당사자소송, 제소기간 등)

구분	사법관계	공법관계
이익 조정	대등한 사익 조정: 신의칙, 권리남용 금지	공익과 사익 형량: 과잉금지, 본질적 내용 침해 금지, 수인의무와 특별한 희생

Ⅴ. 현대적 변용: 공법과 사법의 상대화

오늘날 공·사법의 경계는 고정되어 있지 않다. 한편으로 **사법의 공법화(사회화)**가 진행되었다. 사회국가원리에 따라 노동법, 경제법(공정거래법), 소비자 관련 법률, 주택임대차보호법처럼 사인 간 관계에 국가가 개입하여 사적자치를 수정하는 **사회법** 영역이 생겼다. 계약공정의 원리, 소유권의 공공성, 무과실책임의 도입이 그 예다. 다른 한편으로 **공법의 사법화**도 나타난다. 행정은 공법상 계약, 민간위탁, 사법 형식의 급부행정 등 사법적 수단을 널리 쓴다. 그러나 행정이 사법의 형식을 빌렸다고 공법적 구속에서 벗어날 수는 없으며(**'사법으로의 도피' 금지**), 기본권과 평등원칙 등에 구속된다(**행정사법**). 이처럼 경계가 상대화되었어도 적용 법규, 소송 형식, 강제 수단, 손해전보 체계가 여전히 다르므로 **구별의 실익**은 남아 있다.

Ⅵ. 결론

공법과 사법의 구별은 근대 국가가 **시장(사적자치)**과 **국가(공익과 법치)**를 나누면서 만든 법질서의 기본 설계다. 사법은 개인의 자유로운 자기결정을 보장하고, 공법은 공익을 실현하는 권력을 법으로 묶어 그 권력이 다시 개인의 자유를 침해하지 않도록 한다. 오늘날 두 영역은 서로 스며들고 있지만, 사적 영역의 자율성을 존중하면서 공권력을 법적으로 통제한다는 구별의 목적은 여전히 유효하다. 공법관계와 사법관계를 정확히 구별하는 일은 결국 **어떤 원리로 개인의 자유와 공동체의 이익을 조화시킬 것인가**를 정하는 일이다.

압축 답안 (시간이 부족할 때)

사법관계는 대등한 사인 간의 법률관계로 사적자치가 지배하며 의사 합치로 형성되고, **공법관계**는 행정주체가 공권력·공익 실현 주체로서 사인과 맺는 관계로 공익 실현과 법률적합성이 지배한다(권력관계·관리관계; 국가가 사인과 같은 지위에 서는 국고관계는 사법관계). 구별 기준으로 이익설·종속설·신주체설이 있으나 관계 법규의 목적·성질 등을 종합하여 판단한다(협의취득은 사법상 매매, 수용재결은 처분). 차이점은 ① 원리: 사적자치 vs 법률적합성과 행정법 일반원칙(비례·신뢰보호·자기구속·부당결부금지), ② 형성·절차: 계약·방식 자유 vs 처분과 행정절차법, ③ 효력: 공정력·불가쟁력, ④ 강제: 사인은 자력강제 불가(판결·민사집행) vs 행정청의 자력강제(대집행·이행강제금·강제징수), ⑤ 손해전보: 민법 제750조 vs 국가배상법(헌법 제29조)과 손실보상(헌법 제23조 제3항, 특별한 희생), ⑥ 쟁송: 민사소송법 vs 행정소송법(항고소송·당사자소송), ⑦ 형량: 대등한 사익 조정(신의칙·권리남용 금지) vs 공익 우위 아래의 과잉금지·본질적 내용 침해 금지다. 오늘날 사법의 사회화(노동법·경제법)와 공법의 사법화(공법상 계약·행정사법)로 경계가 상대화되었지만, 적용 법규와 구제 절차가 달라 구별의 실익은 여전하다.

핵심 키워드

국가와 사회의 이원론 · 사적자치 vs 공익 실현 · 권력관계·관리관계·국고관계 · 국가적 공권/개인적 공권 · 이익설·종속설·신주체설 · 협의취득 vs 수용재결 · 법률적합성(법률 우위·유보) · 행정법 일반원칙 · 행정절차법 · 공정력·불가쟁력 · 자력강제 · 국가배상법·손실보상 · 수인의무·특별한 희생 · 행정소송법 · 사법의 공법화·공법의 사법화 · 행정사법